

1500009-64.2021.8.26.0546

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Gomes de Queiroz Coutinho

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) -

2000537/2021 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 15456201 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 4/21/316 -

DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2000537 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

1ª Vara

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi Mirim-SP - cep 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500009-64.2021.8.26.0546 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500009-64.2021.8.26.0546

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) -

2000537/2021 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 15456201 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 4/21/316 -

DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2000537 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2000537/2021 - DEL.POL.MOGI-MIRIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LARISSA MAZZER TOMAZOLI e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Gomes de Queiroz Coutinho

VISTOS:

GILBERTO HENRIQUE DA SILVA MARIELLI e LARISSA MAZZER TOMAZOLI, já qualificados nos autos da ação penal em epígrafe, foram denunciados pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 03 de janeiro de 2021, por volta das 09h26min, na Rua Ariovaldo Silveira Franco, altura do numeral 237, Jardim 31 de Março, neste Município e Comarca de Mogi Mirim, agindo em conjunto e com unidade de desígnios, transportavam e traziam consigo droga, para fins de tráfico, 01 (uma) porção de Cannabis Sativa L, que pesavam aproximadamente 328 g (trezentos e vinte e oito gramas), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com a denúncia, Policiais Militares que realizavam fiscalização de trânsito (bloqueio) de rotina deram ordem de parada a uma motocicleta Honda XRE 300 conduzida pela segunda corré e que tinha o primeiro como "garupa". O comando foi prontamente atendido e ambos os ocupantes do motociclo revelaram certo nervosismo. Feita a busca pessoal, tais agentes públicos encontraram com o corréu GILBERTO um tablete de maconha. Questionado, tal acusado reivindicou a propriedade da droga e disse que se destinava ao seu consumo pessoal. A corré LARISSA por sua vez, admitiu ter conhecimento da droga encontrada com seu namorado.

O Inquérito Policial encontra-se nas fls. 01/137 e vem instruído com o auto de prisão em flagrante, com o boletim de ocorrência alusivo aos fatos, com os autos de exibição e apreensão e de constatação preliminar, com as notas de culpa e com o Relatório da Autoridade Policial.

Os acusados foram então regularmente notificados e apresentaram resposta escrita (fls. 163, 180/181, 186, 194 e 200/210). Recebida a denúncia, seguiram-se as citações pessoais (fls. 218/220, 245 e 258).

Na audiência atermada a fls. 281/282 interrogaram-se os réus e ouviram-se 05 (cinco) testemunhas.

Concluído o incidente de dependência toxicológica instaurado a pedido da defesa do corréu GILBERTO, veio aos autos o laudo respectivo, seguindo-se manifestações das partes (fls. 39/43, 46 e 50/51 do apenso próprio).

Em alegações finais, o D. Promotor de Justiça requereu a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia (fls. 373/383). A I. Defensora nomeada ao corréu GILBERTO arguiu falta de justa causa e, no mérito, postulou a absolvição; subsidiariamente, requereu a desclassificação para aquela infração menos grave inscrita no artigo 28 da Lei de Tóxicos (fls. 387/397). O I. Defensor constituído pela corré LARISSA postulou a absolvição e, subsidiariamente, não apenas a fixação da pena em seu patamar mínimo, mas também o reconhecimento de causa de diminuição da pena (artigo 33, § 4º, do sobredito diploma legal), a substituição da pena por restritiva de direito e a adoção de regime inicial diverso do fechado (fls. 398/407).

Relatados, D E C I D O :

Não desconheço, decerto, a necessidade de a denúncia vir acompanhada de elementos capazes de sugerir a ocorrência da infração penal e a respectiva autoria, atribuindo justa causa à ação que se pretende instaurar. Colha-se, a propósito, a ensinança de JOSÉ FREDERICO MARQUES, para quem é preciso que haja o fumus boni juris para que a ação penal contenha condições de viabilidade. Do contrário, inepta se apresentará a denúncia, por faltar legítimo interesse e, conseqüentemente, justa causa. Imperativo é, por isso, o controle do juiz sobre essa condição de viabilidade do pedido acusatório, pois, se assim não for, pode ser atingido, indevidamente, o status libertatis do acusado. Não há, no caso, um juízo de formação da culpa, com apuração rigorosa do corpo de delito. O que existe é um despacho de delibação, provisório e simples, em que o juiz apura se há aquela fumaça de bom direito que autoriza a intauração da persecutio criminis em sua fase processual. O processo penal atinge o status dignitatis do acusado. Em vários casos, este sacrifício é exigido (como acontece sempre que o réu é absolvido) no interesse do bem comum. Todavia, se nem o fumus boni juris pode descobrir-se, para alicerçar a peça acusatória, seria iníquo que o juiz permanecesse impassível e, como simples autômato, fosse recebendo a denúncia ou queixa".

De igual teor o escólio de JULIO FABBRINI MIRABETE, para quem ultimamente tem se incluído como causa de rejeição da denúncia ou da queixa por falta de condição

exigida pela lei (falta de interesse de agir) a inexistência de elementos indiciários que amparem a acusação. É realmente necessário que a inicial venha acompanhada de um mínimo de prova que demonstre ser ela viável; é preciso que haja *fumus boni iuris* para que a ação penal tenha condições de viabilidade pois, do contrário, não há justa causa. Tem-se exigido, assim, que a inicial venha acompanhada de inquérito policial ou prova documental que a supra, ou seja, de um mínimo de prova sobre a materialidade e a autoria, para que opere o recebimento da denúncia ou da queixa, não bastando, por exemplo, o simples oferecimento da versão do queixoso. Evidentemente não se exige prova plena nem um exame aprofundado e valorativo dos elementos contidos no inquérito policial ou peças de informação, sendo suficientes elementos que tornam verossímil a acusação.

No caso em voga, contudo, a detenção de ambos os acusados se deu mesmo em condições hábeis a sugerir não apenas a posse sobre a substância entorpecente, mas também a destinação comercial. É que o laudo de exame químico toxicológico acostado a fls. 164/166 tem suficiente aptidão para atestar a materialidade do delito. E a quantidade de droga apreendida e a preexistência de condenação definitiva por idêntica infração penal (tráfico de droga) conferem viabilidade à imputação.

Memento: tivesse a I. Advogada feito leitura atenta do laudo médico-pericial produzido no incidente de dependência toxicológica (instaurado a seu pedido, aliás), veria que o louvado negou categoricamente não apenas quadro de doença mental ou perturbação da saúde mental (sic), mas também prejuízo da capacidade de entendimento e de determinação à época dos fatos (sic).

Não há cogitar-se, então, da falta de justa causa referida nas alegações finais do corréu GILBERTO.

Composta a matéria processual, resta decidir o mérito.

Cuida-se de tráfico de entorpecente, delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A pretensão punitiva posta na denúncia é mesmo procedente.

Enquanto a materialidade descende da prova consubstanciada no auto de exibição e apreensão e nos laudos periciais encartados a fls. 09 e 164/166, a autoria restou suficientemente demonstrada com os depoimentos prestados pelas testemunhas de forma segura e coesa, sem dúvidas ou contradições capazes de justificar algum descrédito.

Como se infere do incluso auto de prisão em flagrante, Policiais Militares que realizavam fiscalização de trânsito (bloqueio) de rotina deram ordem de parada a uma motocicleta Honda XRE 300 conduzida pela segunda corré e que tinha o primeiro como "garupa". O comando foi prontamente atendido e ambos os ocupantes do motociclo revelaram certo nervosismo. Feita a busca pessoal, tais agentes públicos encontraram com o corréu GILBERTO um tablete de maconha. Questionado, tal acusado reivindicou a propriedade da droga e disse que se destinava ao seu consumo pessoal. A corré LARISSA por sua vez, admitiu ter conhecimento da droga encontrada com seu namorado.

Quando ouvidos durante a instrução criminal, os Policiais Militares Maxwell Marti e Daniel Siqueira de Souza ratificaram, em sua inteireza, os relatos antes dados ao Delegado de Polícia que presidiu a lavratura do auto de prisão em flagrante; reafirmaram não apenas a abordagem dos acusados naquela fiscalização rotineira de trânsito (bloqueio), mas também, e principalmente, a apreensão daquela relevante porção de droga em poder do corréu GILBERTO (garupa da motocicleta conduzida pela corré LARISSA).

E a despeito do entendimento comumente esposado em casos deste jaez, não há como

inquinar a validade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais (raciocínio extensível aos membros das Guardas Municipais), mormente quando ausente qualquer fato concreto, mínimo que seja, que sugira ou recomende algum descrédito. É que a simples condição de Policial (ou Guarda Municipal) não autoriza conclusão sobre parcialidade ou falta de isenção capaz de infirmar os respectivos relatos, quiçá sobre a sugerida predisposição de imputar crimes a inocentes. Trago à colação v. aresto do C. Supremo Tribunal Federal, relator o eminente Ministro CELSO de MELLO:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC n. 74.608-0 – SP).

Confirmam-se ainda, porque pertinentes, os seguintes julgados do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte (STJ - Resp. 751.760/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 18.10.2005. DJ 14.11.2005, p. 400).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. (...) 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (STJ - AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental não provido.

PROVA CRIMINAL – Depoimento de Policial – Validade – Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. Segurança nas versões apresentadas – Recurso provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra, desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador (Apelação Criminal n. 185.484-3 – São Paulo – 6ª Câmara Criminal – Relator: Djalma Lofrano – 22.06.95).

PROVA CRIMINAL – Hipótese de tóxico – Depoimento prestado por policial – Admissibilidade – Relato que não deixa dúvida alguma do encontro de maconha em poder do agente – Condenação mantida. O agente da polícia serve como testemunha, tal qual qualquer outra pessoa, até porque ele é auxiliar da Justiça criminal e não é de supor-se que se transforme em parte, que compareça a Juízo para perseguir pessoas inocentes, para as quais criam crimes inexistentes (Apelação Criminal n. 159.299-3 – Botucatu – Relator: Djalma Lofrano – 18.08.94).

PROVA CRIMINAL – Testemunhal – Depoimento de policial – Validade – Recurso não provido. O depoimento de policial assume força probante incriminadora, uma vez que, como qualquer pessoa, o policial pode servir como testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade, notadamente se não há elementos indicadores de que tenha ele se desviado do exercício de sua função pública, da qual decorre presunção juris tantum de legitimidade de sua atuação (Apelação Criminal n. 172.521 – São Paulo – 4ª Câmara Criminal – Relator: Bittencourt Rodrigues – 12.06.95).

Aliás, “seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito” (Apelação n. 1.002.771/3, SP, 11a Câmara – Relator: Xavier de Aquino).

As testemunhas (de defesa) Vera Lúcia de Campos, Talita Araújo Vitorino e Rita Beatriz Gusmão de Souza, por sua vez, pouco – ou nada – trouxeram de relevante à solução da pendenga. É que não bastasse a existência de vínculos entre elas e os acusados (são amigos de longa data, causa bastante para se inferir evidente interesse na causa e, por isso mesmo, pouca – ou nenhuma isenção – em seus relatos), tais pessoas não presenciaram os fatos, motivo pelo qual não foram além de enaltecer a vida pregressa dos acusados.

A primeira delas (Vera Lúcia de Campos), aliás, não apenas já testemunhou em favo do corréu GILBERTO noutras duas ações penais (donde se extrai a impossibilidade de sincera e honestamente enaltecer sua vida pregressa), mas também, e principalmente, contradisse o amigo: enquanto GILBERTO disse ter se viciado em maconha quando esteve preso em 2018, a testemunha por ele arrolada disse que o vício se iniciou na adolescência...

Há mais, porém.

Quando dos seus interrogatórios judiciais, os réus nem sequer negaram a posse daquela substância entorpecente, senão apenas a finalidade comercial (o corréu GILBERTO disse trazê-la consigo para seu próprio consumo e a corré MARIELLI disse saber que o namorado o fazia).

Nessa parte, porém, a negativa restou isolada e, por isso mesmo, sem apoio em quaisquer elementos de prova capazes de conferir-lhe mínima credibilidade.

Não bastasse a quantidade deveras relevante da droga e, por isso mesmo, pouco ou nada compatível com o consumo pessoal, o corréu GILBERTO não apenas ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas, mas também, e principalmente, nem sequer tinha trabalho ou renda capaz de garantir-lhe a aquisição de um “tijolo” de maconha que pesava mais de 300g (trezentos gramas).

Dir-se-á – e aliás foi dito – que o dinheiro utilizado para a compra do entorpecente foi recebido a título de empréstimo pela corré LARISSA (sua namorada/esposa/companheira). Certo, mas se tal pessoa tinha profissão deveras modesta (atendente de farmácia) que lhe proporcionada minguados R\$ 1.500,00 (mim e quinhentos reais) mensais, como imaginar pudesse ela com tal numerário pagar a prestação da motocicleta (R\$ 659,00), custear todas as despesas da casa (seu companheiro, não se olvide, estava desempregado) e ainda conservar sobra de outros R\$ 600,00 (seiscentos reais) livres e desimpedidos para ceder, gentil e graciosamente, ao seu consorte para a aquisição de maconha???

O só fato de o corréu GILBERTO fazer consumo eventual daquela substância entorpecente nem tem a relevância que se lhe empresta, porque ressabida a possibilidade de alguém comercializar substância entorpecente e consumi-la por mero deleite.

O laudo produzido nos autos do incidente de dependência toxicológica, ademais, negou categoricamente não apenas quadro de doença mental ou perturbação da saúde mental (sic), mas também prejuízo da capacidade de entendimento e de determinação à época dos fatos (sic).

Conquanto inexistentes atos com idoneidade para indicar a concreta venda de droga na data indicada na denúncia (o possível – senão provável comprador – se evadiu

quando da aproximação policial), cumpre rememorar que a incidência do artigo 33 do sobredito diploma legal prescinde da efetiva negociação. Ali, ao revés, são previstas inúmeras outras condutas, como aquelas postas com clareza solar na denúncia encartada a fls. 148/149 (transportar e trazer consigo). Trago à colação, o seguinte julgado:

Traficante não é apenas aquele que comercia entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e na circulação de drogas, como, por exemplo, aquele que as tem em depósito (TJRS - AC - 69.100.048-3 - Rel. Nilo Wolff - RJTJRS 151/216). Destaquei.

Fixada a responsabilidade do corréu GILBERTO (pelo tráfico, claro), resta perquirir acerca da conduta da corré LARISSA.

E não obstante o hercúleo esforço de seu ilustre Defensor, nada - nada mesmo - autoriza inferir dúvida capaz de conduzir à absolvição.

É que tal acusada nem sequer negou o conhecimento da existência da droga encontrada nas vestes de seu companheiro; ao revés, admitiu, às escâncaras, pleno conhecimento daquela circunstância.

E se tal consorte não apenas tinha condenação definitiva por tráfico de drogas, mas também não exercia qualquer atividade lícita que lhe propiciasse a aquisição de tamanha porção de maconha, difícil crer - sinceramente - pudesse ela desconhecer a finalidade comercial do entorpecente.

Não se deslembre, de resto, que a denúncia atribuiu aos acusados o transporte da droga. E se sabedora do histórico de seu companheiro e da existência de relevante porção de maconha em seu poder, pôs-se a corré LARISSA a conduzir a motocicleta utilizada para o transporte do entorpecente, a absolvição é inimaginável.

GILBERTO HENRIQUE DA SILVA e LARISSA MAZZER TOMAZOLI, então, praticaram fato antijurídico, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a respectiva sanção penal que passo a dosar.

I - Do corréu GILBERTO:

Em atenção ao preceito contido nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, cumpre notar a existência de antecedentes criminais (fls. 153/156 e 157/162). Tais dados denotam péssima conduta social, personalidade voltada para o crime e a mais absoluta indiferença para com a Lei Penal. Justifica-se, pois, o arbitramento de pena base acima do mínimo legal, sob pena de se dispensar ao acusado tratamento idêntico àquele merecido por condenados primários, sem quaisquer tises em sua vida pregressa. E não é só. Não há se olvidar, ainda, a relevante quantidade de droga apreendida (um "tijolo" que pesava quase 330g de maconha). Debuxa-se daí não apenas maior lesão ao interesse jurídico tutelado pela norma, mas também, e principalmente, maior culpabilidade e maior reprovabilidade da conduta. Ora, são sabidos, plenamente sabidos, os malefícios advindos de tais substâncias, assim como a estreita relação existente entre o comércio de drogas e os mais variados e graves crimes. Daí a necessidade de se considerar também tal circunstância, sob pena de se dispensar a ele tratamento idêntico àquele merecido por pessoas que possuem, transportam ou trazem consigo, para o consumo de terceiros, quantia menos significativas. Reporto-me, uma vez mais, à jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

A quantidade de drogas apreendida pode e deve ser utilizada na dosimetria (STJ - HC - 10.165 - Rel. Félix Fischer - j. 9.11.1999 - DJU 14.2.2000, p. 53).

Ao proceder a individualização da pena, o Juiz após aferir um leque de

circunstâncias de natureza subjetiva - culpabilidade, antecedentes, conduta social, e personalidade do agente - e de natureza objetiva - motivos, circunstâncias e conseqüências do crime -, fixará aquela aplicável dentre as cominadas, em quantidade que for necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, definindo, a seguir, o regime inicial de cumprimento de pena, a qual não deve ser excessiva, nem demasiadamente abrandada, mas justa, adequada e idônea, em qualidade e quantidade suficientes para reprimir a prática da infração e promover a tutela da sociedade (STJ - 6a Turma - REsp. 90.171 - Rel. Luiz Vicente Cernichiaro - j. 08.10.1997 - DJU 12.08.1997, p. 36.287).

Para a exarcebção é permitido ao juiz, diante das circunstâncias judiciais, apreciar o alto grau de reprovabilidade da conduta (STJ - 5a Turma - Rel. José Arnaldo da Fonseca - REsp. 195.222 - j. 02.09.1999 - DJU 11.10.1999, p. 83, e RT 773/552).

Com tais premissas, fixo a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O primeiro documento acima referido (fls. 153/156) indica mesmo a reincidência, circunstância agravante a teor do que dispõe o artigo 61, I, do Código Penal. Daí derradeiro acréscimo, à razão de 1/6, para perfazer 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Nem se diga sobre eventual bis in idem, pois os antecedentes considerados para aferição da conduta social e personalidade do réu são diversos daquele capaz de fazer incidir a reincidência:

"Inocorre bis in idem na dupla majoração da pena pelos maus antecedentes e reincidência na hipótese em que o réu ostenta mais de uma condenação definitiva anterior" (TACRIM-SP - Ap - Rel. Fernando Miranda - j. 07.05.1998 - RJTAcrim 39/251).

"Somente ocorre bis in idem na fixação da pena, pela majoração em razão de maus antecedentes e reincidência, quando o acusado possuir apenas uma condenação anterior capaz de gerar aumento a título de circunstância judicial e, depois, pela agravante genérica, o que não há quando há duas ou mais condenações pretéritas, permitindo-se, nestas hipóteses a dupla exasperação" (TACRIM - SP - Ap - Rel. René Nunes - j. 12.02.1998 - RJTAcrim 37/159).

Não há circunstâncias atenuantes (não é caso de se reconhecer confissão espontânea, pois consoante o entendimento consolidado na Súmula nº 630 do C. Superior Tribunal de Justiça, "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecente exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio"; e aqui o réu negou a destinação comercial). Por outra e, ainda que se admitisse - por hipótese mesmo - a confissão, nem seria caso de se fazer redução sob tal rubrica, ante a prevalência das circunstâncias ditas pessoais posta no artigo 67 do Código Penal:

Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual (HC 105543, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 26-05-2014 PUBLIC 27-05-2014). Destaquei.

CONFISSÃO - REINCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO - IMPROPRIEDADE - PRECEDENTES. Prepondera sobre a confissão a reincidência, no que esta última revela a necessidade de

observar-se apenação substancial, não se colocando no mesmo nível o reincidente e o primário (RHC 135819, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018). Destaquei.

Não há, por fim, causas gerais ou especiais de diminuição da pena (à vista das circunstâncias judiciais desfavoráveis, dos antecedentes e, sobretudo, da reincidência, não é caso de aplicação da norma inserta no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos).

Torno definitiva a pena privativa de liberdade deste primeiro acusado, dessarte, em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Fixo a pena pecuniária, outrossim, em 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, previsão legal mínima para o delito modificada a primeira, na mesma proporção, pelos acréscimos oriundos das circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade de droga e maus antecedentes) e da agravante (reincidência). Arbitro o valor unitário do dia multa no mínimo legal, qual seja, um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, corrigido monetariamente até a presente data, à míngua de maiores dados acerca da capacidade financeira do réu.

II - Da corrê Larissa:

Em atenção ao preceito contido no artigo 59 do Código Penal, cumpre notar a inexistência de relevantes antecedentes criminais ou outros elementos capazes de justificar alguma exasperação da sanção nesta fase. À vista da quantidade expressiva da droga e, valendo-me dos argumentos acima postos em relação ao primeiro acusado, fixo a pena base, então, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes, nem atenuantes (não é caso de se reconhecer confissão espontânea, pois consoante o entendimento consolidado na Súmula nº 630 do C. Superior Tribunal de Justiça, "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecente exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio"; e aqui o réu negou a destinação comercial).

Ausentes quaisquer causas gerais ou especiais de aumento de pena, não há como refugir à aplicação daquela causa de diminuição de pena inscrita no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. E à vista de a quantidade de droga já ter sido considerada na primeira fase, faz-se redução aqui à razão de 2/3 (dois terços).

Torno definitiva a pena privativa de liberdade por esta primeira infração, dessarte, em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Fixo a pena pecuniária, outrossim, em 194 (cento e noventa e quatro) dias multa, previsão legal mínima para o delito modificada, na mesma proporção, pelo acréscimo proporcionado pela circunstância judicial desfavorável (quantidade de droga) e pela causa de diminuição da pena (artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos). Arbitro o valor unitário do dia multa no mínimo legal, qual seja, um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, corrigido monetariamente até a presente data, à míngua de maiores dados acerca da capacidade financeira desta corrê.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA posta na denúncia e CONDENO: I) GABRIEL HENRIQUE DA SILVA MARIELLI, já qualificado nos autos, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como no pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias multa, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, I, do Código Penal e; II) LARISSA MAZZER TOMAZOLI, também qualificada, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez)

dias de reclusão, bem como no pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias multa, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Ausentes os requisitos autorizadores, deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade imposta ao corréu GILBERTO por restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal). O crime perpetrado é deveras grave e, por isso mesmo, nem guarda compatibilidade com aquelas sanções mais brandas previstas no sobredito dispositivo legal. Quando do julgamento do Habeas Corpus nº 203.403/SP, aliás, a 5ª Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, relator o eminente Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, assentou que não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou (HC 203.403/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011).

No mesmo sentido o v. aresto proferido em data deveras recente pela C. 4ª Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da apelação nº 0020420-98.2010.8.26.0576, relator o eminente Desembargador Salles Abreu, para quem atualmente, o entendimento majoritário do Colendo Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei 11.343/06, possibilitando, em um caso concreto, a conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. No entanto, o crime continua grave e hediondo, sendo que a substituição penal não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do delito, portanto, não deverá ser aplicada no caso em tela, afastado o pedido subsidiário (Apelação nº 0020420-98.2010.8.26.0576 - São José do Rio Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Salles Abreu - 04/10/2011).

E ainda:

PENA - Restritivas de direitos - Tráfico de entorpecentes - Incompatibilidade com a determinação legal de regime fechado (art. 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90) - Inaplicabilidade dos benefícios da Lei nº 9.715/98 - Recurso improvido (Apelação Criminal nº 877.915-3/8 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Marco Antonio - 17/08/2006).

PENA - Restritivas de direitos - Réu condenado por tráfico de entorpecentes - Substituição da reprimenda privativa de liberdade - Inadmissibilidade - Preliminares rejeitadas e recurso improvido (Apelação Criminal nº 908.095.3/3 - São Paulo - 9ª Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 27/09/2006).

E aqui, como já registrado alhures, tal acusado não apenas tem antecedentes criminais, mas também, e principalmente, é reincidente (específico, não se olvide).

Não tem, por isso mesmo, direito à suspensão condicional da pena (artigo 77 do mesmo Diploma Legal).

O regime inicial do cumprimento das penas impostas há de ser o fechado, único compatível com a gravidade do crime, com a quantidade da sanção, com os antecedentes e, sobretudo, com a reincidência.

Com relação à corré LARISA e, à vista da primariedade, da pena aplicada e, sobretudo, da superveniência de lei que excluiu a hediondez para o caso em testilha (artigo 112, § 5º, da Lei nº 7.210/84, com a redação dada pela Lei nº 13.964/19), não há como refugir à presença dos requisitos alistados no artigo 44 do Código

Penal. Daí porque, deverá tal corré cumprir prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo a entidade pública ou privada com destinação social indicada pelo Juízo da Execução, além de prestar serviços à comunidade pelo mesmo período da sanção ambulatorial, na forma e condições estabelecidas pelo Juízo da Execução.

Sobrevindo o descumprimento da sanção, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto (artigo 33, § 2º, do Código Penal).

Ausentes (em relação a ela) os fundamentos da prisão preventiva, faculto o apelo em liberdade.

Expeçam-se ofícios ao IIRGD comunicando a presente decisão para as anotações e providências pertinentes. Com o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados. Custas e despesas ex lege (artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03). Arbitro a honorária da I. Advogada nomeada ao corréu GILBERTO no valor máximo da tabela respectiva; oportunamente, expeça-se certidão.

P.R.I.C. Mogi Mirim, 18 de janeiro de 2022.

EMERSON GOMES DE QUEIROZ COUTINHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA